

1500207-20.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... configurar reincidência pelo delito de tráfico, além de sofrer processo recente, por furto (1500003-87.2022.8.26.0169).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500207-20.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-20.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053726/2022 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 23228244 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2053726 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2053726 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Alan Antônio Francisco, Fabiano Rodrigues e José Paulo Ferreira da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §4º, II e IV do Código Penal.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 23 de fevereiro de 2022, às 20h30min, na Rua Treze de Maio, quadra 1, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram, para

si, mediante escalada e concurso de agentes, fios de um poste, da vítima, representada por Leandro Garcia Ferreira.

Boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 19/20), auto de avaliação (fls. 22), relatório policial final (fls. 206/207). Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 174/177), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 213/214, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 243, 245 e 247), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 250/257).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 291/293 as partes desistiram da oitiva da vítima Leandro Garcia Ferreira e do PM Robson Rodolfo de Almeida Ribeiro, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas a testemunha de acusação/defesa PM Reinaldo Breve e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 307/312 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, valorando-se os maus antecedentes e personalidades voltadas para crimes dos acusados Alan e Fabiano, utilizando-se uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa, reconhecendo as reincidências dos réus, específicas no tocante à Alan e Fabiano, bem como a agravante do "estado pandêmico", considerando-se a confissão de ambos, com a fixação do regime inicial fechado para os acusados.

Já a Defensoria às fls. 315/319 pleiteou pelo reconhecimento da insignificância penal, pelo suposto baixo valor dos objetos ou, pela absolvição por ausência de provas ou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora da escalada, com a compensação da reincidência de Fabiano e Alan com a confissão de ambos, a fixação de regime mais brando, a substituição da privativa por restritivas de direitos, apenas quanto a José Paulo, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 19/20), auto de avaliação (fls. 22), relatório policial final (fls. 206/207).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O representante da vítima Leandro Garcia Ferreira, ouvida somente durante o inquisitivo (fls. 09), disse que exerce o cargo de Diretor de Divisão de Iluminação Pública. Afirmou que, no dia 15/02/2022, foi feita a colocação de fiação no viaduto da rua Treze de Maio, tendo em vista a subtração dos fios, sendo que, somente a título de material, foram gastos cerca de seis mil reais. Informou que, no dia dos fatos, foi acionado por policiais militares dando-lhe ciência que a fiação do local supramencionado havia sido novamente furtada. Esclareceu que uma equipe de prefeitura foi ao local e constou a subtração. Mencionou que, na delegacia, reconheceu os fios subtraídos como os mesmos que tinham sido instalados, na semana passada, no viaduto da Treze de Maio.

O policial Reinaldo Breve, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em resumo, que receberam informações acerca de um furto em andamento. Afirmou que foram ao local e notaram que a fiação da rede de energia pública estava danificada. Informou que receberam as informações de que o crime teria sido praticado por três pessoas. Esclareceu que, na posse das características deles, saíram em diligências e os encontraram na Avenida Nuno de Assis, sentido favela São Manoel. Mencionou que, com o réu José Paulo, que trajava bermuda verde, havia uma mochila, contendo diversos fios, duas facas e uma serra. Citou que o acusado Fabiano confessou o crime, dizendo que havia escalado o poste enquanto os demais réus ficaram aguardando, enquanto o acusado Alan confessou que iriam trocar aqueles fios por drogas na favela São Manoel. Disse que somente Jose Paulo permaneceu calado. Afirmou que eles foram detidos cinco quarteirões do local onde ocorreu o crime.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Alan, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que caminhava com Fabiano, quando notaram um pedaço de fio pendurado, ocasião em que pegaram aquela fiação. Afirmou que foram abordados pela polícia na via pública. Informou que Fabiano estava com facas porque trabalhava com jardinagem. Esclareceu que foram subtraídos cerca de cinco metros de fio.

Já o acusado Fabiano, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disse que estava com Alan quando apanharam os fios no viaduto da Treze de Maio. Afirmou que foram abordados por policiais. Informou que José Paulo somente estava no local e ajudou a enrolar os fios e o colocá-los na bolsa. Esclareceu que foram subtraídos cerca de 20 metros de alumínio, que pretendiam vender no fero velho.

Por fim o acusado José Paulo, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse que apenas passava pelo local, quando foi abordado pelos policiais.

No tocante a José Paulo, tem-se que sua conduta também é incriminadora.

Com efeito, Alan disse que ele estava no local e ajudou a enrolar os fios e colocá-los na bolsa.

Depois de cinco quarteirões foram todos surpreendidos por policiais, sendo que os milicianos presenciaram que José Paulo portava uma mochila com os fios, além de uma serra e duas facas.

Assim, as confissões espontâneas dos acusados Alan e Fabiano encontram arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155 §4º, IV do Código Penal.

Isto porque, no tocante à escalada, não foi acostado o respectivo laudo pericial, providência que era possível na espécie.

Basta citar que no boletim lavrado acerca da ocorrência assim constou (fls. 13/16): "Fora solicitada perícia no local do evento, sendo este preservado por policiais

militares (protocolo 280/2022)".

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL.

IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. É de afastar-se a aplicação da Súmula n. 182, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

3. Observada a aplicação da figura privilegiada pelo Tribunal de origem (art. 155, § 2º, do CP), e tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis e que o recorrente é primário, sendo, ainda, de pequena monta o valor da res furtiva (R\$ 702,82), afigura-se mais benéfico ao apenado o afastamento da pena corporal, aplicando-se-lhe apenas a reprimenda de 10 dias-multa.

4. Entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão confirmatório transcorreu prazo superior aos 2 anos de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 114, I, do CP.

5. Provimento do agravo regimental. Conhecimento do agravo.

Provimento ao recurso especial, aplicando ao recorrente a pena de 10 dias-multa, com o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 2061101 / MG, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 02/08/2022)

Tampouco, é caso de reconhecimento da insignificância penal.

Primeiro, como adiante se verá, os réus possuem vasto "histórico criminal".

Tal circunstância, de per si, impede o manejo da bagatela própria.

No sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALOR DAS RES FURTIVAS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À

ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no REsp 1804399/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019).

II - In casu, além do valor do bem (R\$ 98,00) ser maior que 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R\$ 788,00 - 2015), verifica-se "[...]em desfavor do réu [...] os processos n.º 2.016/2.010.0001984 -0 e n.º 016/2.010.0006149-9 que caracterizam reincidência", a impedir a aplicação da bagatela.

III - "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EAREsp nº 221.999/RS, firmou "a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no AREsp 1.204.004/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/03/2018).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1952212 / RS, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 05/10/2021)

Além disso, no caso concreto, o furto de fios, em concurso de agentes, causa imenso prejuízo, seja no tocante ao interesse público primário (da coletividade, aqui visto como a interrupção do serviço de energia elétrica), ou mesmo o interesse público secundário (da Administração, no aspecto, gastos públicos com a instalação de novos cabos).

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Sob outro aspecto, devem os réus permanecerem custodiados.

Como dito, eles são reincidentes, inclusive, Fabiano e Alan detém reincidência específica em seu desfavor (fls. 106/163).

Já o acusado José, possui condenação anterior transitada em julgado, apta a configurar reincidência pelo delito de tráfico, além de sofrer processo recente, por furto (1500003-87.2022.8.26.0169).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Réu Alan Antônio Francisco

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos: 1699/02, 5206/2010, 38294/11 e 19408-17.2007.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são deletérias.

Como dito, a Administração Pública dispendeu grande montante no restabelecimento da fiação (cerca de 6 mil reais), o que tinha feito há apenas uma semana.

Além disso, é notório que a coletividade experimenta graves prejuízos, principalmente, pela suspensão, ainda que momentânea, da energia elétrica no local. Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo. Deste modo, a pena deve ser exasperada em 5/6, atingindo 3 (três) anos e 8 (oito)

meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há dois feitos que representam reincidências específicas.

São os de nº 15984-49.2016 e 20645-42.2014.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/5, pois a agravante específica exige maior reprovação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Assim, a reprimenda perfaz 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 21 (vinte e uma) diárias.

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do “estado pandêmico” deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que ‘não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19’.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da

participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Réu Fabiano Rodrigues

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos: 19195/2002, 1276/04, 14650/06, 3989/2011 e 11850-04.2014.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são deletérias.

Como dito, a Administração Pública gastou elevado montante no restabelecimento da fiação (cerca de 6 mil reais), o que tinha feito há apenas uma semana.

Além disso, é notório que a coletividade experimenta graves prejuízos, principalmente, pela suspensão, ainda que momentânea, da energia elétrica no local.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser duplicada, atingindo 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há três feitos que representam reincidências específicas.

São os de nº 1500015-92.2019, 13026-81.2015 e 20586-40.2016.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 2/5, pois a agravante específica exige maior reprovação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não

fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Assim, a reprimenda perfaz 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) diárias.

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Réu José Paulo Ferreira da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são deletérias.

Como dito, a Administração Pública gastou elevado montante no restabelecimento da fiação (cerca de 6 mil reais), o que tinha feito há apenas uma semana.

Além disso, é notório que a coletividade experimenta graves prejuízos, principalmente, pela suspensão, ainda que momentânea, da energia elétrica no local. Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, atingindo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, há um feito que representa reincidência: 1500357-35.2021.

Assim, a reprimenda deve ser agravada em 1/6, atingindo 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) diárias.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

O regime é o inicial fechado para todos os acusados.

Com efeito, Fabiano e Alan são portadores de maus antecedentes e reincidências específicas.

Já no tocante à José ele é reincidente, e, além disso, possui ao menos um feito, também por furto, em andamento.

Portanto, o regime mais gravoso serve para reprimir as condutas e, também, para ressocializar os acusados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MENOR DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)" (AgRg no RHC 160.457/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Paciente é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentado. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 722608 / SP, relator ministra Laurita Vaz, julgado em 05/04/2022)

As reincidências, impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal deduzida na ação penal e, desta maneira, CONDENO os acusados:

ALAN ANTÔNIO FRANCISCO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

FABIANO RODRIGUES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA